

1500372-50.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2036975/2021 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 16120550 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 17/21/819 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 2036975 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

1500372-50.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500372-50.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2036975/2021 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 16120550 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 17/21/819 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 2036975 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZA ANTONIA QUEIROZ LEAL LIMA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Vistos.

LUIZA ANTONIA QUEIROZ LEAL LIMA e GUSTAVO MOTOS DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, c. c. o artigo 40, inciso VI (adolescente), ambos da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 29, caput, do Código Penal, porque, segundo a peça acusatória, no dia 8 de fevereiro de 2021, por volta das 17h30min, na via pública da Rua Antônio de Luca, bairro Glebas Beatriz, neste município e comarca, durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19 (cf. Decreto Estadual n. 64879 de 20.03.2020, publicado no DOE-SP de 21.03.2020), agindo em concurso entre si e com o adolescente R. F. N., venderam,

traziam consigo e tinham em depósito, com intuito de tráfico ilícito, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a saber, 06 (seis) porções de Erythroxylon coca, popularmente conhecida como cocaína, 1 (uma) porção da mesma substância sob a forma de "crack", e 01 (uma) porção de Cannabis sativa L., popularmente conhecida como maconha.

Notificados a apresentar defesa preliminar, a qual foi juntada às fls. 159/163 (Luiza) e fls. 176/177 (Gustavo), com denúncia recebida às fls. 181/182.

LUIZA passou a ser representada pela Defensoria Pública nos termos de fl. 217.

Em audiência (fl. 259), foram ouvidas três testemunhas arroladas na denúncia, uma arrolada pela Defesa e interrogada a ré LUIZA, sendo decretada a revelia do réu GUSTAVO.

Em memoriais, o Ministério Público pleiteou a condenação nos termos da denúncia (fls. 263/272), ao passo que a Defesa pugnou pela absolvição, ou, subsidiariamente, a desclassificação ou fixação de pena e regime mais favoráveis (fls. 276/292).

É o relatório.

Decido.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls.05/07, pelo boletim de ocorrência de fls.25/28, pelo auto de exibição e apreensão de fls.29/30 e imagens de fls.33/38, pelo laudo de constatação de fls.40/43 e laudo toxicológico de fls.112/114, gravação das diligências policiais (anexada ao termo de audiência- fl. 259), bem como pela prova oral coligida.

A autoria também é certa e deve ser imputada aos réus.

Os policiais civis Rafael Silva Varuzza, Ricardo Alfredo Coelho e Jane Aparecida da Costa realizavam diligência no local dos fatos utilizando uma viatura descaracterizada, quando avistaram os denunciados e o adolescente em atividade típica de mercancia ilícita. Ato contínuo, os policiais civis começaram a filmar a ação e visualizaram quando o denunciado GUSTAVO efetuou cinco vendas de entorpecentes, após o que entregou o dinheiro recebido para que LUIZA o guardasse. Da mesma forma, foi visualizando quando o adolescente R. também realizava a comercialização ilícita e ocultava as drogas em uma vegetação rasteira existente nas proximidades. Diante desse quadro, foi efetuada abordagem, apreendendo perto de GUSTAVO uma porção grande de "crack". Já com LUIZA foi localizada a quantia de R\$85,00. Por sua vez, o adolescente R. trazia consigo duas porções de maconha e a quantia de R\$ 50,00. Em seguida, os policiais diligenciaram no local onde Rena foi visto ocultando um objeto, apreendendo outras seis porções de cocaína.

A ré, em seu interrogatório, negou os fatos, afirmando que havia feito um "programa" para Gustavo e que ele entregou a ela a quantia de R\$ 85,00 pelo "programa", sendo que o valor era de R\$ 100,00, mas ele descontou R\$ 15,00 por conta da droga que ele havia comprado para que ela e ele (Gustavo) usassem juntos. O réu Gustavo não compareceu para dar sua versão em interrogatório.

A versão de LUIZA, porém, restou isolada nos autos.

Referida ré foi filmada pelos policiais em plena atividade de traficância (conforme gravação das diligências policiais anexada ao termo de audiência- fl. 259) e, para tentar dar uma justificativa, inventou a história de que se tratava de dinheiro relativo a "programa".

Ocorre que a vez em que foi filmada não foi a única em que realizou o procedimento. De fato, como narrado pelos policiais, antes de realizar a filmagem eles já haviam visto como o trio operava (os dois réus e o adolescente): o denunciado GUSTAVO efetuava a venda, após o que entregava o dinheiro recebido para que LUIZA o guardasse, enquanto o adolescente R. também realizava a comercialização ilícita e ocultava as drogas em uma vegetação rasteira existente nas proximidades.

Os policiais não conheciam os réus antes dos fatos, de modo que deve ser dada prevalência ao depoimento dos policiais, que se mostraram firmes e uníssonos.

Nesse sentido a doutrina de SILAS SILVA SANTOS e JOSÉ WELLINGTON BEZERRA DA COSTA NETO: "o policial intervém em ocorrência como sujeito imparcial, agente do Estado que, salvo peculiaridades inerentes a algum caso concreto, desconhece os envolvidos e com eles não tem relações que pudessem ensejar preferências ou antipatias. Não pode ser tachado de parcial pelo fato de tomar as providências de seu ofício. Basta

pensar na figura do magistrado: após proferir sentença, na qual necessariamente assumirá alguma posição em relação à pretensão punitiva, não passa a ser considerado sujeito parcial" (in Considerações críticas acerca do valor do depoimento de agente policial no processo penal, RT-901, novembro de 2010, pp. 474-475).

Comprovada, ainda, a participação do adolescente, diante da prova produzida, não havendo que se falar em desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, pois demonstrada a venda dos entorpecentes.

Passo à dosimetria da pena.

Quanto a Gustavo, orientado pelas diretrizes fixadas pelo art. 59 do Código Penal, diante dos maus antecedentes (Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 1501518-97.2019.8.26.0320- fls. 255/256), elevo a pena em 1/6, isto é, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Conforme já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, "condenações por fatos anteriores ao apurado na ação penal sob debate, ainda que com trânsito em julgado posterior, justificam o aumento da pena-base pela valoração de maus antecedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ AgRg no AREsp n. 35.077-SP Rel. Min. Marco Aurélio Belizze 5ª T. j. 02.04.13).

Para Luiza, a pena-base fica estabelecida no mínimo.

Na segunda fase da aplicação da reprimenda, não há agravantes ou atenuantes a considerar (até por conta do disposto, quanto a Luiza, na Súmula 231 do STJ). Deve ser afastada a agravante inominada em razão da prática do crime no estado de calamidade pública.

Ressalvado meu posicionamento pessoal, a jurisprudência e a doutrina caminham no sentido de que deve ser provado o dolo específico de se valer da situação de calamidade para praticar o delito, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido: "A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva (...). Hipótese em que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial." (AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.ª T., j. 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

Na terceira e última fase, não há que se falar na aplicação, para Gustavo, do disposto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por conta dos maus antecedentes.

Comprovada, ainda, a causa de aumento do artigo 40, inciso VI (adolescente) da Lei 11.343/06, elevo a pena em mais 1/6, isto é, 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

O regime inicial será o fechado (art. 33, § 3º do CP).

Quanto a Luiza, na terceira e última fase, diante da incidência da causa de aumento prevista no inciso VI do art. 40, da Lei 11.343/06, elevo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, bem como 583 dias-multa.

A seguir, presente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (admitindo a concomitância das causas de aumento e diminuição, vide Apelação nº 0015988- 62.2010.8.26.0050, da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo), reduzo a pena de dois terços, máximo permitido, para fixar definitivamente à ré a pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa.

Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, "[o] ato infracional cometido pelo agente quando inimputável não pode ser utilizado como fundamento para se deduzir a dedicação à atividades criminosas, principalmente quando inexistente nos autos provas de práticas delitivas reiteradas." (HC 179.159, Relator Gilmar Mendes, DJe 19.12.2019).

Na mesma linha: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO. ATOS INFRACIONAIS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO". (AgR no HC 184.979/SP, Relatora Cármen Lúcia, Segunda Turma, Dje 07.08.2020).

Para referida ré, fica estabelecido o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos: prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo e prestação de serviços à comunidade pelo tempo da condenação.

Tendo em vista a revisão do TEMA 931 pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em decisão datada de 24 de novembro de 2021, "na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade."

A D. Procuradoria Geral de Justiça, nesse sentido, chegou a editar a Resolução 1.433/2022, em 3 de março de 2022, dispensando os membros do Ministério Público de executar as penas de multa por conta do referido julgado de efeito vinculante (art. 927, III, do CPC).

No caso dos autos, tendo em vista que os réus foram representados pela Defensoria Pública, há presunção de hipossuficiência, de modo que, desde logo, JULGO EXTINTA a punibilidade da pena de multa, não sendo razoável sobrecarregar a Serventia para intimação dos sentenciados, após o trânsito em julgado, para que eles aleguem a hipossuficiência quando esta se faz presente desde logo. Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional, o contingente da população prisional em laborterapia corresponde ao ínfimo patamar de 13,9%, ou seja, um total de apenas 92.213 pessoas, das quais 70,34% auferem valores entre 1 e 2 salários mínimos.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão ministerial e CONDENO o réu GUSTAVO MOTOS DA SILVA, qualificado nos autos, a cumprir, em regime inicial fechado, a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e LUIZA ANTONIA QUEIROZ LEAL LIMA, qualificada nos autos, a cumprir, em regime inicial aberto, a pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, substituída por prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo e prestação de serviços à comunidade pelo tempo da condenação, dando ambos como incursos no artigo 33, caput, c. c. o artigo 40, inciso VI (adolescente), ambos da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 29, caput, do Código Penal.

Os réus poderão recorrer em liberdade.

Declaro o perdimento dos bens e dinheiro apreendidos em poder dos réus ora condenados.

Fica autorizada a incineração da droga, caso ainda não tenha ocorrido.

Condeno os acusados ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que são beneficiários da assistência judiciária gratuita, já que com os interesses patrocinados pela Defensoria Pública.

P.R.I.

Limeira, 5 de maio de 2022.

GUILHERME LOPES ALVES LAMAS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA